

<제2장 근로관계의 성립.제3절 근로계약과 근로관계>

I. 근로관계의 의의

- 근로관계란 근로자가 사용자에게 노무를 제공하고 사용자는 그 대가로 임금을 지급하는 것을 내용으로 하는 법률 관계를 의미한다. 근로관계는 단순히 노동력을 거래하는 민사 관계를 넘어, 사용자의 지휘·명령권과 근로자의 종속 관계가 형성되는 특수성을 가진다. 근로관계의 성립은 개별적 근로관계법인 근로기준법을 비롯한 모든 노동법적 보호의 기초가 된다. 근로관계는 근로계약을 통해 발생하며, 계약의 내용대로 근로가 현실적으로 제공되는 상태를 포괄하는 개념이다.

II. 근로계약과 근로관계

- 근로계약과 근로관계는 서로 밀접하게 연관되어 있으나, 그 개념과 발생 시점에는 차이가 있다.

1. 근로계약

- 근로계약은 당사자 간의 합의에 의해 장래 근로관계를 발생시키는 것을 목적으로 하는 법률 행위이다. 이는 낙성계약으로서 당사자 간의 의사 합치만으로 성립하며, 근로 제공이 현실적으로 이루어지기 전에 성립할 수 있다. 근로계약은 근로관계의 내용을 규정하는 기준이 되지만, 근로기준법 등 강행 법규에 의해 그 내용의 자유가 제한된다.

2. 근로관계

- 근로관계는 근로계약의 체결과 더불어 근로 제공이 현실적으로 시작되어 근로자가 사용자의 지휘·명령 하에 종속되어 있는 계속적 사실 관계이자 법률 관계이다. 근로관계가 성립해야 비로소 해고 제한, 휴가 부여, 퇴직금 지급 등 근로기준법상 모든 권리와 의무가 현실적으로 발생한다. 따라서, 근로관계는 근로계약을 기초로 하지만, 실제 노무 제공이라는 사실을 통해 구체화되고 지속되는 법적 상태를 의미한다.

3. 양자의 관계

- 근로계약은 근로관계를 발생시키는 원인 행위이고, 근로관계는 근로계약에 따라 발생하고 유지되는 결과 상태이다. 근로계약이 무효나 취소로 효력을 잃더라도, 이미 제공된 노무에 대해서는 사실상 근로관계가 존재했던 것으로 보아 임금 등의 법적 보호를 받을 수 있다. 근로관계의 존부는 근로계약의 형식보다 실질적인 사용종속관계를 통해 판단된다.

4. 통설과 판례

- 유효한 근로계약이 체결되면 이와 동시에 근로관계가 성립한다는 견해(계약설)와 유효한 근로계약 이외에 근로자의 작업개시 또는 경영체제로의 편입이라는 사실적 요소가 필요하다는 견해(편입설)가 있으나, 판례는 근로관계가 성립하기 위하여는 양 당사자 사이에 명시적 또는 묵시적으로 체결된 계약이 있거나, 기타의 법적 근거가 있어야 한다고 하여 계약설의 입장을 취하고 있다.

III. 비전형적 근로관계

- 비전형적 근로관계란 정규직 근로계약처럼 확정적이고 완전한 근로관계가 아닌, 장래 본 계약 체결을 예정하거나, 본격적인 근로관계 성립 전 일정한 평가 기간을 두는 등 특수한 형태로 성립되는 근로관계를 의미한다. 대표적으로 채용내정과 시용이 있다.

1. 채용내정

(1) 의의

- 채용내정은 사용자가 근로자에게 장래 일정한 시점(주로 졸업 후)에 근로계약을 체결할 것을 약속하고, 근로자가 이를 승낙함으로써 성립되는 관계이다. 주로 신입 채용에서 발생하며, 내정 통보 후 입사 전까지의 기간 동안 일반적인 근로관계는 아니지만 특정 법적 효력을 가지는 상태를 말한다.

(2) 법적 성격

- 판례는 채용내정을 해약권이 유보된 근로계약으로 본다. 즉, 내정 통보와 승낙이 있을 때 이미 근로계약은 성립하지만, 사용자가 일정한 사유(졸업 요건 미달 등)가 발생하면 일방적으로 계약을 해지(해약)할 수 있는 권한을 유보한 것으로 해석한다.

(3) 해약권의 행사

- 사용자의 해약권 행사는 일반적인 근로계약의 해지와 동일하게 취급되어, 근로기준법상 해고 제한 법리가 유추 적용된다. 즉, 사용자가 채용내정을 취소(해약권 행사)하기 위해서는 정당한 이유가 있어야 하며, 채용내정 당시 유보된 취소 사유라 할지라도 그 사유가 사회통념상 합리적인 것이어야 한다. 정당한 이유 없이 취소하면 부당해고와 마찬가지로 무효가 될 수 있다.

2. 시용

(1) 의의

- 시용(試用)은 본 채용 전, 근로자의 업무 적격성, 능력, 인성 등을 평가하기 위하여 일정 기간 동안 시험적으로 근로를 제공하는 것을 의미한다. 시용 기간 동안 근로자는 사용자의 지휘·명령 하에 실질적인 노무를 제공한다.

(2) 법적 성격

- 시용은 해약권이 유보된 근로계약이라는 점에서 채용내정과 동일한 성격을 가진다. 다만, 채용내정은 노무 제공 개시 전의 상태인 반면, 시용은 실제 노무 제공이 시작된 상태라는 차이가 있다. 따라서, 시용 기간 중에는 근로기준법이 적용되며, 시용 근로자도 근로기준법상 근로자로서 보호받는다.

(3) 본 채용 거부(해약권 행사)

- 시용 기간이 종료된 후 사용자가 본 채용을 거부하는 것(시용 계약의 해지) 역시 해약권 행사로 간주되며, 근로기준법상 해고 제한 법리가 유추 적용된다. 다만, 시용은 근로자의 적격성 평가라는 목적이 있으므로, 정규 채용 근로자에 대한 해고 사유보다는 더 넓게 정당성을 인정한다. 판례는 본 채용 거부가 객관적이고 합리적인 이유에 근거하고, 사회통념상 상당하다고 인정되는 경우에 한하여 정당성이 인정된다고 판시한다. 단순히 마음에 들지 않는다는 주관적인 이유는 정당한 이유가 될 수 없다.

(4) 시용 기간 중의 해고

- 시용 기간 중에 사용자가 근로자를 해고하는 경우, 이는 해약권 행사가 아니라 일반적인 해고에 해당하며, 근로기준법 제23조의 정당한 이유가 요구된다. 다만, 시용 기간이 3개월 이내인 경우에는 근로기준법 제26조에 따른 해고 예고 의무가 적용되지 않는다.

IV. 결론

- 근로계약은 근로관계의 발생을 목적으로 하는 원인 행위이며, 근로관계는 계약을 기초로 실제 노무 제공을 통해 발생하고 지속되는 사용종속적 결과 상태이다. 채용내정과 시용은 근로관계 성립의 과도기적인 형태인 비전형적 근로관계로서, 판례는 두 가지 모두 해약권이 유보된 근로계약으로 본다. 채용내정 취소나 시용 기간 종료 후 본 채용 거부는 근로기준법상 해고 제한 법리가 유추 적용되어 정당한 이유가 있어야 효력이 인정된다. 이는 근로자의 계속 근로에 대한 기대권을 보호하고 사용자의 자의적 계약 해지를 방지하여 노동법적 안정성을 확보하기 위함이다.